

三、将执行完毕后的前罪作为后罪的入罪标准予以评价，不存在累犯、再犯等重复评价的情形

李某某曾因盗窃受过刑事处罚，以750元作为认定其盗窃数额较大的标准，同时认定李某某系累犯，予以从重处罚，并不涉及重复评价。李某某在实施本次盗窃行为之前，曾因盗窃受到过5次刑事处罚，5次均被判处有期徒刑，且本次犯罪系在前次有期徒刑刑罚执行完毕后5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，故将李某某上述5次受过刑事处罚情况分别作为认定500元为数额较大和累犯的依据，不存在重复评价情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条是对盗窃“数额较大”所作的特别规定。根据本条，盗窃数额达到《解释》第一条规定标准的50%，并具有相应情形的，即属于法律规定的“数额较大”。换言之，本条是在法律规定的框架内，对盗窃“数额较大”明确的另一个具体认定标准，故对根据本条已构成盗窃罪的行为人，如同时符合累犯成立条件的，依法从重处罚，并不存在双重从重问题。当然，由于已将累犯作为定罪情节考虑，体现了对累犯从严惩处的立法精神，因此，在具体量刑时，要掌握好从重处罚的幅度，不宜增加过多的刑罚量，但这与累犯的认定并无冲突。

综上，李某某曾因盗窃受过刑事处罚，再次盗窃达到数额较大标准的50%，构成盗窃罪，并属于累犯，从重处罚。

编写人：广西壮族自治区贺州市中级人民法院 欧枝剑

采取挂失手段非法占有他人转入本人银行卡的资金， 挂失期间尚未取出资金属于盗窃未遂

—— 方某某等盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省济南市中级人民法院(2023)鲁01刑终18号刑事判决书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

2020年9月，被告人方某某与黄某某明知他人利用信息网络实施犯罪行为，基于非法占有的目的，共同商议将方某某名下的银行卡提供给上游违法行为人用于接收违法资金，待资金进入账户后通过挂失银行卡的方式占有卡内资金，被告人黄某甲亦加入该行为。为及时接收进账信息，方某某通过微信绑定了涉案银行卡。后，有被害人卢某某的被诈骗资金35万元汇入方某某的银行卡，其中10万元随即被上游违法行为人转出，黄某某通知黄某甲电话挂失银行卡，卡内尚有25万元未转出，三人在银行临时挂失到期后通过微信转出5万元，并随即办理了正式挂失。挂失期间，黄某某被公安机关抓获，后黄某某带领公安人员将方某某、黄某甲抓获。三被告人归案后对上述犯罪事实供认不讳。

【案件焦点】

为非法占有他人转入本人银行卡的资金而办理银行卡挂失，其间行为人未取出的资金是盗窃既遂还是未遂。

【法院裁判要旨】

山东省济南市市中区人民法院经审理认为：被告人方某某、黄某某、黄某甲以非法占有为目的，事前共谋通过采取挂失银行卡的手段秘密窃取他人财物，数额巨大，三人的行为构成盗窃罪。黄某甲已将方某某的银行卡挂失，卡内资金已由方某某等人实际控制，属于盗窃既遂。山东省济南市市中区人民法院对被告人方某某、黄某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对被告人黄某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，作出如下判决：

被告人方某某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币2万元。被告人黄某某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元。被告人黄某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。

一审宣判后，方某某、黄某某、黄某甲提出上诉。

山东省济南市中级人民法院经审理认为：黄某某、方某某二人事先共谋，在明知他人购卡用于非法活动的情况下，以非法占有他人违法行为所得资金为目的，向他人出售银行卡，在相关款项进入银行卡后，黄某甲明知款项来源，仍听从黄某某指示，与方某某二人实施了挂失银行卡并取现的窃取行为，原审判决认定三人均构成盗窃罪是正确的。三人在钱款转入后，除通过微信转出的5万元外，因银行规定、侦查机关侦查活动等意志以外原因未能对其余资金实际控制，应认定尚未取出的20万元系犯罪未遂，一审法院对此认定不当，应予以纠正。综上，山东省济南市中级人民法院对方某某、黄某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十三条之规定，对上诉人黄某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第二十三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，作出如下判决：

方某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币19000元；黄某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币19000元；黄某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币14000元。

【法官后语】

盗窃是侵财类案件常见的犯罪手段，此类案件具有高发性，司法实践中亦存在盗窃既遂与未遂的认定难题，在具体把握认定盗窃既未遂的标准上常有分歧与争议。因此，准确界定此类案件的既未遂标准不仅是统一司法裁判尺度的内在要求，更是刑法罪责刑相适应原则的应有之义，同时对被告人的量刑具有重要意义。

关于盗窃罪的既遂标准，刑法理论的通说则采用“控制说”作为认定标准，“控制说”认为，认定盗窃既未遂应以行为人是否实际控制所盗财物为判断标准。行为人已经实际控制、占有被盗财物的为盗窃既遂，未实际控制、占有财物的为盗窃未遂。司法实践中，认定盗窃既未遂的标准在于把握好本罪构成要件的客观方面。盗窃罪的客观构成要件表现为秘密窃取公私财物的行为，“所谓秘密窃取，就是行为人采取不易被财物所有人、保管人或其他人发现的方法，将公私财物非法占有的行为”，据此可以得出当行为人通过秘密窃取的手段实现了非法占有财物的主观目的时，可认定为盗窃既遂。因此，行为人是否已经非法占有他人财物是判断盗窃既遂与未遂的标准。而以盗窃罪犯罪构成要件的客观方面作为判断既未遂的方法与刑法理论的通说“控制说”是一致的。因此，我们可以采取“控制说”来界定盗窃既未遂的标准。

所谓“控制”指的是所有人或其他人对财物进行事实上的管领和支配，财物处于被现实利用的动态控制之中，这种动态控制不是一种法律上的使用资格，而是一种改变权利人对财物原有的支配关系，建立一种新的行为人与财物之间的支配关系，其具体表现为利用者或者财物所有人对财物不受阻碍地进行利用的一种状态。“控制”作为“占有”的一种外部表征，只有具有实现财物所有权的使用、收益处分权能的“控制”才算得上作为盗窃既遂标准的“控制”。此外，在认定盗窃既遂与未遂时，必须根据财物的性质、形状，被害人对财物

